

1500561-13.2022.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500561-13.2022.8.26.0637 - Controle 2022/000690

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISES GUILHERME DE CARVALHO

Aos 11 de outubro de 2022, às 16:00h, na sala de audiência virtual da Vara Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura no Provimento CSM nº 2.651/2022 e pelos Comunicados CG nº 284/2020 e CG nº 208/2022, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça MARCELO BRANDÃO FONTANA, do(a) Dr(a). Defensor KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA, OAB/SP nº 405439 e do réu. Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. Foi oportunizado à Defesa o direito de contato reservado com o réu através do sistema virtual. A seguir foram ouvidas as testemunhas do rol acusatório Flávio e Pedro, e, ao final, o(a) réu(é) foi interrogado(a) sobre os termos da acusação, de acordo com o artigo 188, incisos I a VIII do CPP, mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e determinava a realização dos debates, tendo sido dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que se manifestou mediante sistema de gravação. Dada a palavra a Defesa, reiterou a manifestação do Ministério Público, requerendo ainda a aplicação do redutor do parágrafo §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de Moises Guilherme de Carvalho, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006. Segundo consta na denúncia de fls. 93/95, *ipsis litteris*:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 04 de maio de 2022, às 06h30, na Rua Gastão Vidigal, 817, na cidade de Herculanópolis e Comarca de Tupã, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros, 24 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 67,7 gramas (peso bruto 75,43g); 10 porções de cocaína, em forma de crack, com peso líquido de 3,33 gramas (peso bruto 9,69g); 05 "pinos" (eppendorfs), contendo cocaína, com peso líquido de 0,71 gramas (peso bruto 7,97g), e mais 09 "pinos" (eppendorfs) de cocaína, com peso líquido de 2,37 gramas (peso bruto 11,57g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15 e laudo de constatação de fls. 17/20). As referidas substâncias causam dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98. Segundo se apurou, o denunciado promovia o tráfico de entorpecentes nesta cidade de Tupã e, para tanto, as drogas eram adquiridas de fornecedor não identificado, e destinadas ao consumo de terceiros. Ocorre que, na ocasião dos fatos, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram até a residência do denunciado e, após adentrarem o imóvel, encontraram o denunciado e mais três usuários de drogas sendo dois deles adolescentes. Após realizar buscas no imóvel, os policiais encontraram 24 porções de maconha e 10 porções de "Crack", que estavam sobre um "rack", localizado na sala da residência. Os policiais ainda encontraram mais 14 "pinos" (eppendorfs), contendo cocaína, que estava ao lado de um sofá, assim como a quantia em dinheiro de R\$ 56,70 (cinquenta e seis reais e setenta centavos) em notas diversas e moedas. As drogas foram apreendidas (fls. 15) e submetidas a laudo de constatação de fls. 17/20, Observa-se que a forma de acondicionamento, quantidade e variedade de porções apreendidas, as informações prévias do comércio de drogas, a presença de usuários de drogas no local, assim como as demais circunstâncias, são elementos indicativos de que o denunciado promovia o comércio ilícito de entorpecentes.

Inquérito policial e diligências às fls. 01/90. Oferecimento de denúncia às fls. 91/95. Promovida a notificação às fls. 96/112. Informações em Habeas Corpus às fls. 113/138 e 144/155. Mandado de notificação cumprido às fls. 139/140. Defesa prévia às fls. 156/160. Réplica ministerial às fls. 164/165. Recebimento da denúncia às fls. 166/168. Expediente de intimações e providências diversas às fls. 169/266. Realizada audiência nesta data. O Ministério Público reiterou a condenação. A defesa técnica postulou a condenação no mínimo legal a aplicação do parágrafo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas no patamar máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pese a manifestação defensiva em memoriais finais, o édito condenatório em desfavor de MOISES desvela-se insofismável, nos termos doravante esposados. Destarte, encerrada a instrução probatória, cumpre destacar que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, de acordo com o auto de prisão em flagrante (fls. 01 e ss), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 15), laudos periciais das drogas (fls. 17/20 e 86/90), comprovante de depósito judicial (fls. 85), relatório final do Douto Delegado de Polícia (fls. 79/82), bem como pelas provas orais produzidas em solo policial e ratificadas em audiência, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório:

A testemunha FLAVIO DELGADO DE MELO, policial civil ouvido na fase inquisitiva às fls. 08, declarou *ipsis litteris* o seguinte: Que nesta data, por volta das 06h00min, em cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã, compareceram na residência de Moisés Guilherme de Carvalho. Que acessarem o interior do imóvel se depararam com dois adolescentes na sala e em um quarto estava o investigado Moisés e um segundo indivíduo. Que passaram a vistoriar o imóvel e sobre um "rack" localizado na sala encontraram 24 porções de maconha embaladas de forma própria para a venda em plástico transparente e 10 porções de "Crack" também embaladas de forma própria para a venda. Acrescentou que também foram localizados 14 "pinos" (eppendorfs) de cocaína que estava ao lado

de um sofá Também foi apreendida q quantia em dinheiro de R\$ 56,70 (cinquenta e seis reais e setenta centavos) em notas diversas e moedas provenientes da venda de drogas. Os adolescentes foram identificados como sendo Breno Felipe Oleriano e João Carlos Silva dos Santos e se declararam usuários de maconha assim como o maior de idade Luiz Paulo Barboza da Silva. Que diante dos fatos o investigado Moisés e os demais indivíduos juntamente com as substâncias entorpecentes e dinheiro foram apresentados nesta unidade policial e Moisés recebeu voz de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas e corrupção de menores. Foi feito uso de algemas para evitar tentativa de fuga. Os laudos de constatações indicaram que as substâncias apreendidas em poder de Moisés eram realmente entorpecentes.. Em Juízo, FLAVIO disse que no dia dos fatos chefiava a equipe de apoio à Delegacia de Herculândia. Na residência do acusado, teria encontrado os entorpecentes na sala da residência do acusado.

A testemunha PEDRO GERALDO M. RODRIGUES, policial civil ouvido na fase inquisitiva às fls. 10, declarou *ipsis litteris* o seguinte: Que nesta data, por volta das 06h00min, em cumprimento de mandado de busca domiciliar expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã, compareceram na residência de Moisés Guilherme de Carvalho. Que ao acessarem o interior do imóvel se depararam com dois adolescentes na sala e em um quarto estava o investigado Moisés e um segundo indivíduo. Que passaram a vistoriar o imóvel e sobre um "rack" localizado na sala encontraram 24 porções de maconha embaladas de forma própria para a venda em plástico transparente e 10 porções de "Crack" também embaladas de forma própria para a venda. Acrescentou que também foram localizados 14 "pinos" (ependorfs) de cocaína que estava ao lado de um sofá Também foi apreendida a quantia em dinheiro de R\$ 56,70 (cinquenta e seis reais e setenta centavos) em notas diversas e moedas provenientes da venda de drogas. Os adolescentes foram identificados como sendo Breno Felipe Oleriano e João Carlos Silva dos Santos e se declararam usuários de maconha assim como o maior de idade Luiz Paulo Barboza da Silva e confirmaram que estavam usando drogas naquele local. Que diante dos fatos o investigado Moisés e os demais indivíduos juntamente com as substâncias entorpecentes e dinheiro foram apresentados nesta unidade policial e Moisés recebeu voz de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas e corrupção de menores. Foi feito uso de algemas para evitar tentativa de fuga. Os laudos de constatações indicaram que as substâncias apreendidas em poder de Moisés eram realmente entorpecentes. Em Juízo, PEDRO disse que no dia dos fatos prestou serviço em apoio a delegacia de Herculândia. Ao dar cumprimento ao mandado de busca domiciliar, foram encontrados entorpecentes na residência do acusado, na sala do imóvel.

A testemunha JOÃO CARLOS SILVA DOS SANTOS, ouvido na Delegacia às fls. 11, declarou *ipsis litteris* que: Que na noite de ontem foi até na residência de Moisés juntamente com Luiz Paulo. Que pouco tempo depois chegou ao local o adolescente Brendo. Que passaram a jogar vídeo-game, acrescentando que fumou maconha juntamente com Moisés e Luiz Paulo. Que todos dormiram no local e nesta manhã foram acordados por policiais civis que estavam cumprindo um mandado de busca. Que todos foram submetidos a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Com relação as drogas localizados por policiais civis na residência de Moisés alegou que não viu drogas naquele local além da maconha que fumaram.

A testemunha BRENDY FELIPI OLERIANO, ouvido na Delegacia às fls. 12, declarou *ipsis litteris* que: Que na noite de ontem estava na casa de Moisés jogando vídeo-game com mesmo. Que chegaram ao local Luz Paulo e o adolescente João Carlos e todos passaram a jogar vídeo-game e foi dormir e na manhã de hoje foi acordado por policiais civis que estavam cumprindo um mandado de busca domiciliar. Que não viu drogas na residência de Moisés.

A testemunha LUIZ PAULO BARBOZA CARDOSO, ouvido na Delegacia às fls. 13, declarou *ipsis litteris* que: Que está atualmente com 18 anos e reside na cidade de Sagres/SP e estava provisoriamente na casa de parentes que na data de ontem foi até a residência de Moisés juntamente com o adolescente João Carlos e naquele local já estava o adolescente Breno. Que começaram a jogar video-game e fumaram "maconha". Que continuaram jogando e todos dormiram na residência de Moisés. Que nesta manhã foram acordados por policiais civis que durante cumprimento de mandado de busca

encontraram drogas na residência de Moisés. Afirmou que em revista pessoal os policiais civis nada encontraram com o depoente. Alegou que não tinha visto drogas na casa de Moisés antes da chegada dos policiais civis. Que é usuário de maconha e já foi apreendido por tráfico de droga na cidade de Osvaldo Cruz/SP.

O acusado MOISES GUILHERME DE CARVALHO, ouvido na fase inquisitiva às fls. 14, manifestou-se nos seguintes termos: Que cientificado das imputações contra si existentes e após entrevistar-se com seu defensor constituído manifestou-se no sentido de apresentar sua versão sobre os fatos somente em Juízo, valendo-se do direito constitucional de permanecer em silêncio e não fazer prova contra si mesmo. Interrogado em Juízo, MOISES confessou a prática delitiva. Mencionou que no dia dos fatos foi surpreendido pela polícia civil em sua residência, sendo encontrado os entorpecentes no local. Disse que as drogas eram destinadas para venda.

Pois bem; não há quaisquer dúvidas acerca da dinâmica dos fatos. Os policiais foram uníssomos ao explicar que cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de MOISES. Durante a diligência, apreenderam 24 (vinte e quatro) porções de maconha, 10 (dez) porções de crack e 14 (catorze) porções de cocaína.

Logo, nada há que desabone a versão dos investigadores, que estavam em contato direto com os fatos e relataram a ocorrência com coesão e harmonia. E, diante da quantidade e variedade de substância, bem como pela existência de prévia investigação, resta indiscutível que a conduta do increpado amolda-se ao art. 33 da Lei de Drogas.

Quanto à seriedade da palavra policial, é digno de nota que o art. 202 do Código de Processo Penal possui a categórica redação de que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Significa dizer que, ressalvado o disposto no art. 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo prestar o compromisso legal. De outro vértice, incumbe ao Magistrado, na forma do art. 155 da Lei Adjetiva, avaliar todas as provas amealhadas e, uma vez formada sua convicção, proceder à exposição dos fundamentos conforme o art. 93, inciso IX, da Magna Carta. Em suma, este Juízo colhe a prova oral e analisa concretamente com os demais elementos dos autos, sem quaisquer presunções prévias positivas ou negativas.

Dessume-se facilmente deste caderno processual que os depoimentos policiais são harmônicos, firmes e coesos, encontrando amparo nos demais substratos de prova (notadamente a apreensão de drogas e dinheiro, realização de perícia, etc). Comungo o mesmo posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que pacificou que “não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha” - RHC 108586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 09/08/2011. Em idêntico sentir, invoco: “(...)

Fundamentação da sentença: valoração da prova com prestígio aos testemunhos dos policiais, fornecendo subsídios que convenceram o magistrado acerca da versão contida na denúncia. (...) Inocorrência de nulidade da sentença, eis que foi cumprida rigorosamente a noção de correlação entre acusação e sentença. Observância do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)” - excerto da ementa do HC 91883, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., j. 24/06/2008.

Em vetusta decisão da Suprema Corte, colige-se o posicionamento pacífico de que:

“PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.

Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido” - HC 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, julgado em 04/08/1998.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido iterativamente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto “(...) a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (...)” -

HC 477.171/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/11/2018. Em idêntico sentir, "(...) não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado (...). É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ (...)" - HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017.

Não bastasse o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, inexistente lógica no aparato do Estado: (I) realizar concurso público para as carreiras policiais; (II) selecionar os indivíduos com a melhor classificação nas avaliações teóricas, práticas e psicotécnicas; (III) submete-los a treinamento intenso nas Academias; e (IV) conferir-lhes o monopólio do uso da força para prevenir, combater e investigar a prática de crimes - inclusive com autorização de porte de arma de fogo e materiais bélicos - e, de forma contraditória, simplesmente desconsiderar as suas palavras quando são chamados a depor na fase inquisitiva e em Juízo. Aliás, consoante as ponderações do Excelentíssimo Desembargador Alcides Malossi Junior (excerto do voto da Apelação 1500527-90.2018.8.26.0471, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgada em 24 de junho de 2020, sem grifos originais):

"não há como se alegar que as palavras de funcionários públicos, diretamente envolvidos no evento, não mereçam credibilidade, porquanto foram sérias e harmônicas, não havendo nos autos qualquer elemento a demonstrar que estivesse ele a mentir, para imputar um delito a pessoa que soubessem ser inocente. A presunção juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder deles, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito. Ademais, seria um contrassenso o Estado lhes dar crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestar contas de suas atividades". Registre-se ainda que os substratos probatórios colhidos na fase policial, quando referendados judicialmente, podem servir de base a édito condenatório, conforme resta pacificado na Suprema Corte, pois a "condenação lastreada em provas obtidas na fase inquisitorial e posteriormente submetidas ao crivo do contraditório, justificando a condenação do réu e afastando a hipótese de nulidade do processo. Embora vedado o revolvimento probatório na estreita via do habeas corpus, seria possível reconhecer, no bojo do writ, uma eventual ocorrência de nulidade. Não é, contudo, o caso dos autos, em que o julgamento está lastreado em acervo probatório fartamente indicado na decisão atacada (...)" - HC 93627, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T., DJe 05/02/2009.

De mais a mais, "é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 'os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo' (...). Dessa feita, os depoimentos prestados por réus e testemunhas na fase policial, na parte em que harmônicos com a prova documental e com a prova oral colhida em juízo, podem servir para a formação do convencimento judicial quanto à responsabilidade penal do agente" - AP 618/RJ Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 13/12/2016.

Colige-se dos autos que não há qualquer indício de que os policiais civis tenham confabulado, de forma vil e abjeta, para mentir na Delegacia e em Juízo, com o escopo de acusar uma pessoa inocente. Assim, não vislumbro margem para o acolhimento do pleito absolutório por fragilidade das provas.

- No mérito da imputação, cumpre destacar que este Magistrado compreende que o art. 28, §2º, da Lei de Drogas, interpretado a contrario sensu, permite a análise casuística para se aferir se os entorpecentes são destinados a consumo próprio ou

ao tráfico. Referido posicionamento também foi sufragado na Apelação 0045618-90.2015.8.26.0050, Rel. Des. Grassi Neto, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/06/2018. Ainda na seara exegetica, também é aplicável o art. 51, inciso I, do mesmo diploma legal, para permitir o balizamento da situação fática perante a tipicidade em abstrato do delito de tráfico de drogas.

Segundo as diretrizes dos preceptivos em comento, analisando a natureza (maconha, crack e cocaína) e a quantidade de substâncias apreendidas (quarenta e oito no total), o local e às condições em que se desenvolveu a ação (diligência da Polícia Civil com ordem judicial, com a localização de drogas e dinheiro), as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, indiscutível que as drogas eram destinadas a terceiros. Assim, não há que se cogitar em absolvição ou desclassificação (que são matérias de ordem pública e cognoscíveis ex officio).

O Egrégio Colegiado Bandeirante tem decidido, de forma assente e pacífica, que são as especificidades do caso concreto (quantidade e variedade das substâncias apreendidas, local dos fatos, desenvolvimento da conduta, antecedentes policiais/criminais do acusado, dentre outros dados empíricos) que permitem a análise e a conclusão da subsunção do fato ao art. 33 da Lei de Drogas. Em abono, vide os seguintes julgados: Apelação 0002856-33.2016.8.26.0597, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, 10ª Câmara de Direito Criminal, r. 12/05/2020; Apelação 1500370-44.2019.8.26.0484, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª Câmara de Direito Criminal, r. 12/05/2020; Apelação 1540082-77.2018.8.26.0451, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, 2ª Câmara de Direito Criminal, r. 11/05/2020.

Cumpra registrar ainda que, para a caracterização do delito em tela, não se exige a finalidade lucrativa, tampouco que ao agente tenha praticado a conduta de venda e/ou entrega de estupefaciente a usuários. Invoco como ratio decidendi o abalizado escólio de RENATO BRASILEIRO DE LIMA (Legislação Criminal Especial Comentada, Volume Único, Editora Juspodum, 5ª edição, p. 1.007/1.012, sem destaques originais) que, em explanação quanto aos DEZOITO verbos e à tipicidade do crime do art. 33 da Lei de Drogas, leciona o seguinte:

“Todas as condutas acima mencionadas têm o complemento ainda que gratuitamente, ou seja, sem cobrança de qualquer preço ou valor. Portanto, é de todo irrelevante haver ou não lucro, ou mesmo intuito de lucro. Os vários núcleos verbais constantes do art. 33 da Lei de Drogas fazem dele um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Assim, mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da alternatividade (...). Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que para a tipificação desse crime dispensa qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (dezoito) verbos constantes do art. 33. Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado, pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies de tipos congruentes, vez que há perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo – o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou o especial fim de agir)”.

No mesmo sentir, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma

com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. 3. A reavaliação dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. 4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado. 5. Agravo regimental não provido. AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 23/03/2020.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INTENÇÃO DE TRAFICAR 329G (TREZENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS) DE MACONHA APREENHIDOS COM O AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA PRÁTICA DE UMA DAS DEZOITO CONDUTAS RELACIONADAS A DROGAS PARA QUE HAJA A CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO PENAL. 1. "O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido - AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 28/08/2019.

Considerando a doutrina e o firme entendimento jurisprudencial, forçosa a conclusão de que a tipicidade do crime de tráfico é extraída das circunstâncias do caso concreto, em cotejo com todo o mosaico probatório. No caso em tela, a apreensão de diversas porções fragmentadas e embaladas (quarenta e oito no total), mais a quantia em dinheiro - sem olvidar existência de investigações prévias, permitem concluir, de forma indene de dúvidas, que a conduta de MOISES amolda-se ao art. 33 da Lei de Drogas.

Com relação à CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA estampada no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, por se tratar de matéria de ordem pública, destaco a possibilidade de aplicação na situação em comento.

Em que pese a variedade de substâncias, verifico que a somatória das porções corresponde a 48 (quarenta e oito) unidades. Não se trata de quantidade vultosa para os parâmetros locais, o que traz dúvida relevante quanto à dedicação ao tráfico e integração de organização criminosa.

Logo, os substratos probatórios colhidos são inócuos para demonstrar, de forma indene de dúvida, que o réu efetivamente dedicava-se ao comércio espúrio. Assim, pelo cenário de incerteza quanto à dedicação ao tráfico e participação em organização criminosa (notadamente pela reduzida quantidade de drogas e ausência de prova de reiteração delitiva), forçosa a aplicação do brocardo in dubio pro reo. Reputo que há prova segura da existência de fato típico, antijurídico e culpável e, plenamente convicto pela condenação de MOISES GUILHERME DE CARVALHO, por infração ao art. 33, §4º, da Lei Federal 11.343/2006, passo à DOSIMETRIA DA PENA, concorde ao critério trifásico do art. 68 do Estatuto Repressor.

Na primeira fase da dosagem, em respeito ao art. 59 do Código Penal, não vislumbro motivos para alteração. Todavia, atento ao art. 42 da Lei Federal 11.343/2006, verifico que a natureza da droga encontrada com o sentenciado (cocaína) é extremamente nociva à saúde pública, bem como detém alto poder destrutivo, causando assim um considerável grau de dependência. O Colendo Tribunal da Cidadania sedimentou o entendimento de que a cocaína justifica o incremento da sanção pela nocividade destas drogas. A respeito, vide os precedentes: AgRg no HC 476.995/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T. DJe 03/05/2019; HC 404.692/PB, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., DJe 08/05/2018; HC 306.565/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T. STJ, DJe 07/05/2015; HC 186.626/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe

23/04/2012. Assim, exaspero a pena base em 1/6 (um sexto) e parto de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Já na segunda etapa da dosimetria, não incidem quaisquer circunstâncias genéricas agravantes (art. 61 do Código Penal). Vislumbro a incidência da confissão espontânea. Assim, mitigo a pena base ao mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado do STJ, fixando a sanção intermediária em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Por fim, na terceira fase do procedimento dosimétrico, não noto a incidência de causas de aumento de pena previstas no Código Penal ou na Legislação Especial. Todavia, de outro vértice, vislumbro a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Federal 11.343/2006, tendo em vista a primariedade e bons antecedentes do acusado. A despeito de se indicar o comércio, não há prova o bastante de que o réu se dedique efetivamente à atividade criminosa. Desta forma, considerando que foram apreendidas 48 porções, que não é uma quantidade desprezível, mas de três tipos de drogas, reduzo a pena intermediária em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 3 anos e 04 meses de reclusão, e 333 dias-multa.

Ausentes provas concretas acerca das condições financeiras e econômicas do condenado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional, de acordo com o art. 43 da Lei Federal 11.343/2006 c/c o art. 49, § 1º, Código Penal, pois inexistem elementos para estabelecer a reprimenda pecuniária acima do piso expresso na legislação especial e no Diploma Geral.

Em respeito ao estabelecido no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em se tratando de sentenciado primário e que ostenta circunstâncias judiciais favoráveis (art. 59 do mesmo diploma), o quantum de pena aplicado e a natureza da sanção, estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o ABERTO, de acordo com os verbetes sumulares 718 e 719 do Excelso Pretório.

Impende ainda salientar que se perfaz plenamente possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, tendo em vista o quantum de pena fixado (inferior a quatro anos), o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e ainda pela culpabilidade, antecedentes, a personalidade e conduta social do réu, os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que tal medida se afigura suficiente à reprovabilidade da conduta do réu e à prevenção criminal. No mais, a vedação do art. 44 da Lei de Drogas foi declarada inconstitucional pelo E. STF (vide o HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 01.09.10), razão pela qual cabe ao julgador analisar o caso concreto.

Logo, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE UM SALÁRIO MINIMO NACIONAL, de sorte que todos os parâmetros serão definidos pelo Douto Juízo da Execução. O réu deverá ser expressamente ADVERTIDO de que, em caso de descumprimento, haverá a conversão da pena restritiva em sanção corporal, que será executada imediatamente.

- Em arremate, atento ao disposto nos incisos do §2º do art. 315 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019), cumpre destacar que os demais argumentos deduzidos pelas partes não são capazes, ao menos em tese, de infirmar a conclusão adotada por este Magistrado - uma vez que houve exaustiva análise de todas as proposições fáticas e jurídicas suscitadas pela acusação e defesa.

De acordo com o abalizado escólio de RENATO BRASILEIRO DE LIMA (Manual de Processo Penal, 8ª edição, Editora JusPodivm, p. 1.094 e 1.611, sem destaques originais), "claro que a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação. A concisão, nos dias de hoje, é uma virtude, e em nada se revela incompatível com o disposto no art. 315, §2º, do CPP. Destarte, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação: aquela jamais dará ensejo à nulidade do art. 564, inciso V, do CPP, desde que enfrentadas, logicamente, todas as questões cuja resolução, em tese, tenham o condão de influenciar a causa".

No mais, prossegue o autor explicando que "quanto à necessidade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pela defesa por ocasião da prolação da sentença, os Tribunais Superiores têm entendido que não há falar em nulidade da sentença se

ficar evidenciado que todas elas foram apreciadas pelo magistrado, ainda que de maneira sucinta, direta ou indiretamente. Embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se desnecessária a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, restar claro que o Julgador adotou posicionamento contrário. Assim, não se tem como omissa uma sentença que, conquanto não se refira, expressamente, a um suposto álibi apresentado pelo acusado, fundamente sua condenação com base em elementos probatórios válidos que confirmem a prática delituosa e a respectiva autoria". Conforme já decidido pelo Excelso Pretório no tocante à fundamentação na seara do Direito Processual Penal, certo que "não há divergência entre o que decidido pelo Tribunal a quo e o entendimento do Supremo Tribunal segundo o qual 'o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento' (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 23.5.2008) (...)" - AI 742202 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 06/04/2010.

Além disso, "(...) prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que 'o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte' (AgRg no AREsp n. 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017) (...)" - excerto da ementa do AgRg no HC 466.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. do Superior Tribunal de Justiça, DJe 10/05/2019.

Também é digno de nota que o mesmo Sodalício, em exame do art. 489 do Código de Processo Civil (cuja redação é idêntica ao do preceptivo introduzido no Código de Processo Penal pelo projeto chamado de "Pacote Anticrime"), firmou o posicionamento que "(...) conforme entendimento pacífico desta Corte: 'O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016) (...)" - excerto da ementa do REsp 1832993/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T. STJ, DJe 13/12/2019.

Dispositivo

1) Ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para CONDENAR o acusado Moises Guilherme de Carvalho como incurso no art. 33, §4º, da Lei Federal 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade correspondente a 3 anos e 04 meses de RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, em seu parâmetro mínimo legal.

2) Satisfeitos os pressupostos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE UM SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, cujos moldes para o cumprimento serão oportunamente designados pelo Douto Juízo da Execução.

3) Em respeito ao estabelecido no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, tendo em vista o término da instrução criminal, não verificando a existência de circunstâncias cautelares concretas, notadamente pelo quantum de pena, o regime aberto fixado e a substituição adrede, em homenagem aos princípios da homogeneidade e proporcionalidade (e atento à concessão de Habeas Corpus), DEFIRO ao réu o direito de recorrer da presente decisão em liberdade.

4) Em face da condenação supra, o sentenciado MOISES arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual 11.608/2003.

5) Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso

Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, DECRETO O PERDIMENTO DE BENS, consistente no depósito judicial de fls. 85;

6) Oportunamente, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, determino que se proceda ao seguinte:

I) providencie-se o necessário à execução da pena imposta acima e cobre-se a taxa judiciária;

II) oficie-se ao TRE/SP, para o cumprimento da regra estabelecida no inciso III, do art. 15, da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD;

III) comunique-se a Autoridade Policial para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do art. 72 da Lei de Drogas;

IV) transfira-se o dinheiro em favor do Funad/Senad.

PRIC".

Saem intimados os presentes, inclusive quanto ao prazo recursal. Ministério Público: Deseja recorrer desta sentença: () Sim (X) Não. Defesa: Deseja recorrer desta sentença: (X) Sim () Não. Réu: Deseja recorrer desta sentença: (X) Sim () Não.

Pela Defesa foi manifestado o desejo de apelar nos termos do artigo 600, §4º. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso de apelação, consignando-se a opção externada pela Defesa de apresentar as razões na Instância Superior. Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Seção Criminal, com as cautelas de praxe e homenagens de estilo.". Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Nada mais. Do que para constar, lavrei este termo, que lido vai devidamente assinado. Eu, _____, Bruno Luís Betti, escrevente técnico judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006